

1500089-52.2019.8.26.0593

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIANO DA SILVA MORENO

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIZIANA DOS SANTOS MARQUES e outro

Juiz de Direito: Dr. FABIANO DA SILVA MORENO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra ELIZIANA DOS SANTOS MARQUES, qualificada às fls. 08/09, e LUCAS AGAPITO, qualificado às fls. 60/62, como incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

3ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, n 110, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500089-52.2019.8.26.0593 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500089-52.2019.8.26.0593

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIZIANA DOS SANTOS MARQUES e outro

Juiz de Direito: Dr. FABIANO DA SILVA MORENO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra ELIZIANA DOS SANTOS MARQUES, qualificada às fls. 08/09, e LUCAS AGAPITO, qualificado às fls. 60/62, como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal.

Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 09 de março de 2019, por volta das 09h31min, na Penitenciária de Marília, localizada na Rodovia SP 294, nº 465, ELIZIANA DOS SANTOS MARQUES, qualificada às fls. 08/09, agindo previamente ajustada

e com unidade de desígnios com LUCAS AGAPITO, trazia consigo e transportava, nas dependências e imediações de estabelecimento prisional, para fins de tráfico, 01 (uma) porção de "cocaína", com peso líquido de 6,84 gramas, e 01 (uma) porção de Cannabis sativa L, droga popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 42,02 gramas, substâncias entorpecentes que determinam dependência psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação de fls. 17/18 e laudo químico-toxicológico de fls. 57/59.

Consta ainda que, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, LUCAS AGAPITO, qualificado às fls. 60/62, concorreu, de qualquer modo, para que sua companheira Eliziana dos Santos Marques praticasse o crime descrito no parágrafo anterior.

Segundo o apurado, a investigada foi flagrada pelas agentes penitenciárias durante a revista realizada por meio do "body scanner", enquanto ingressava no estabelecimento prisional com as porções de cocaína e maconha escondidas em sua vagina, para a realização de visitas ao seu companheiro LUCAS, para quem entregaria os entorpecentes.

Conduzida à sala reservada, ELIZIANA confessou a prática delitiva, alegando que passava por dificuldades financeiras, inclusive retirando os entorpecentes que trazia em sua vagina. LUCAS concorreu para que ELIZIANA trouxesse consigo a droga, uma vez que seria o destinatário do entorpecente, responsável por disseminá-lo no interior do presídio.

As circunstâncias da prisão, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, o local de sua destinação - Penitenciária - são fatores que tornam certo o destino da droga ao consumo de terceiras pessoas dentro da unidade prisional.

Auto de prisão em flagrante às fls. 05.

Boletim de ocorrência às fls. 11/13.

Auto de exibição e apreensão às fls. 14/15.

Laudo de constatação às fls. 17/18.

Realizada a audiência de custódia, foi convertida a prisão da acusada Eliziana em preventiva às fls. 39/41.

Laudo definitivo às fls. 57/59.

Determinada a notificação dos acusados, indeferido o pedido de prisão preventiva do denunciado LUCAS, bem como substituída a prisão preventiva imposta à ré ELIZIANA por prisão domiciliar às fls. 86/87.

Notificado o acusado LUCAS às fls. 108/109 e a acusada ELIZIANA às fls. 123/126, apresentaram defesa preliminar às fls. 130/131.

Recebida a denúncia em 11/11/2019 e designada audiência de instrução para o dia 16/03/2020 às fls. 136.

Revista e mantida a prisão domiciliar da ré ELIZIANA às fls. 187, 201, 226/227

Concedida a liberdade provisória a ré ELIZIANA, com imposição de medidas cautelares às fls. 258/259.

Decretada a revelia da acusada ELIZIANA e encerrada a instrução às fls. 299.

Realizada a audiência de instrução, oram colhidos os depoimentos das testemunhas Elizabeth da Silva e Luzinete Duarte do Nascimento, bem como decretada a revelia do acusado Lucas Agapito e determinado que se deprecasse o interrogatório da ré Eliziana dos Santos Marques à Comarca de Registro (fls. 167/168).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais escritas às fls. 302/305, e requereu que a ação seja julgada procedente, nos termos da denúncia. Em relação à pena, requereu que, na primeira fase, a pena seja fixada pouco acima do mínimo legal para ambos acusados, considerando a natureza de um dos entorpecentes. Na segunda fase, observou que a acusada é primária, mas o acusado é multirreincidente específico, motivo pelo qual a pena deve ser elevada para ele. Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, III da Lei 11.343/06, uma vez que o crime foi cometido nas dependências de estabelecimento prisional, não devendo ser reconhecido o tráfico privilegiado. Requereu seja fixado o regime inicial fechado, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A douta Defesa, em alegações finais escritas às fls. 312/320, requereu a absolvição

de ambos acusados, sob argumento de que não existem provas suficientes para sustentar a condenação. Em relação a acusada Eliziana, requereu a exclusão de sua confissão informal às agentes penitenciárias, em respeito ao direito ao silêncio. Em relação ao acusado LUCAS, alegou que inicial acusatória não descreve qualquer conduta típica que tenha sido praticada por ele, o que inviabiliza o exercício do contraditório, devendo ser ele absolvido. Subsidiariamente, em relação à ré Eliziana, em caso de condenação, requereu a concessão do benefício do artigo 33 § 4º da Lei 11.343/06, tendo em vista que preenche os requisitos para tal, devendo ser fixado regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É O RELATO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

A materialidade do delito restou sobejamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante às fls. 05, boletim de ocorrência às fls. 11/13, auto de exibição e apreensão às fls. 14/15, laudo de constatação às fls. 17/18, laudo definitivo às fls. 57/59, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Passo à análise da autoria.

Eis a prova oral colhida.

A testemunha Elizabeth da Silva, agente penitenciária, em audiência, narrou que a acusada passou pelo scanner e, na imagem, já foi possível visualizar a droga. Questionada, a acusada e entregou a droga, cocaína e maconha, informou que tinha mais maconha que cocaína. Informou que a droga foi encontrada dentro de um objeto do tamanho aproximado de um "Kinder Ovo". Negou que a acusada tenha dito que entregaria a droga ao réu, disse que entregaria a droga para um terceiro que não sabia quem era e que essa pessoa iria lhe procurar ali dentro.

A testemunha Luzinete Duarte do Nascimento, agente penitenciária, em audiência, esclareceu que a acusada não disse que entregaria a droga para o seu marido e sim que seria para um terceiro que iria lhe procurar dentro do presídio, disse que havia cometido o crime, pois estava passando por dificuldades financeiras.

A acusada ELIZIANA DOS SANTOS MARQUES, em solo policial, permaneceu em silêncio. Ausente sua versão judicial, tendo sido decretada sua revelia.

O acusado LUCAS AGAPITO, em solo policial, negou que tenha qualquer relação com a conduta da esposa, foi surpreendido com a informação de que a sua esposa estaria levando drogas para dentro do presídio, afirmou que nunca pediu para que a esposa levasse droga para dentro do presídio, sendo assim nega qualquer envolvimento com os fatos. Ausente sua versão judicial, tendo sido decretada sua revelia.

Pois bem.

Em que pese a tese sustentada pelo nobre Dr. Defensor, a pretensão deduzida pelo Ministério Público comporta parcial acolhimento.

Isto porque, ao cabo da instrução processual, restou amplamente demonstrada a responsabilidade da acusada ELIZIANA pela prática do delito narrado na denúncia.

Nesse sentido, é firma e segura toda a prova deduzida, notadamente em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Veja-se que, tanto em solo policial como em Juízo, as agentes penitenciárias Elizabeth da Silva e Luzinete Duarte do Nascimento afirmaram, de forma uníssona, que, ELIZIANA foi submetida ao aparelho "body scanner", ao ingressar na Penitenciária de Marília para visitar seu companheiro, o corréu LUCAS, quando visualizaram algo suspeito na imagem. Ao ser conduzida a uma sala reservada e questionada, a ré confessou que trazia introduzida em sua vagina um invólucro contendo maconha e uma ínfima quantidade de cocaína, tendo, ela mesma, retirado a substância.

Informou Elizabeth que a ré "entregou a droga" e, ainda, "informou que tinha mais maconha que cocaína". As testemunhas esclareceram, ainda, que ELIZIANA informou que praticava o delito porque estava passando por dificuldades financeiras, sendo que ambas afirmaram, em Juízo, que ela não disse que estava levando o entorpecente para seu companheiro. Inclusive, Luzinete explicou que, segundo a ré, a droga destinava-

se “para um terceiro que iria lhe procurar dentro do presídio”. Frise-se que não há qualquer motivo pelo qual não se possa atribuir total crédito a tais depoimentos, não havendo nos autos quaisquer indícios de que as agentes penitenciárias tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente a ré.

Como se sabe, o depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Sendo assim, seus testemunhos são harmônicos e coerentes entre si e estão em plena consonância com as demais provas dos autos, não havendo motivo para desprezá-los apenas por se tratarem de agentes públicos ou para colocar sob suspeita sua palavra, sendo extremamente temerário dela desacreditar em contexto probatório desta envergadura.

Desse modo, o depoimento das agentes penitenciárias, bem como as circunstâncias em que a droga foi apreendida, sugerem a prática do nefasto comércio. Cumpre registrar, ainda, que, para a caracterização do delito em tela, não se exige que o agente tenha atingido a finalidade lucrativa, tampouco que tenha praticado a conduta de venda e/ou entrega do entorpecente a usuários.

Isto porque o crime de tráfico de entorpecentes é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inseridos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento.

In casu, restou devidamente demonstrado que a ré ELIZIANA trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, o entorpecente apreendido, nas dependências de estabelecimento prisional, incidindo, portanto, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06.

Lado outro, o mesmo não se pode dizer em relação ao réu LUCAS, na medida em que não há provas suficientes de sua autoria no delito que lhe foi imputado.

Muito embora evidenciado a prática do delito de tráfico pela companhia do réu, não há evidências concretas de que LUCAS seria o receptor do entorpecente apreendido, ou mesmo que soubesse que sua companheira estava levando drogas à Penitenciária.

Veja-se que ambas as testemunhas, ouvidas em Juízo, informaram que ELIZIANA não apontou o companheiro como receptor. Ao contrário, segundo ela, a droga seria entregue a um terceiro que entraria em contato com ela já dentro do presídio. Nesse passo, é bom lembrar que, em matéria de condenação criminal, não bastam indícios. A prova deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu LUCAS deve prevalecer.

E conforme se verifica do contexto probatório, a prova é imprecisa, não ensejando segurança para autorizar um decreto condenatório, máxime em se tratando de crime considerado hediondo, com consequências jurídicas gravíssimas.

Ademais, a respeito da precariedade de provas, o entendimento que vem prevalecendo em nossos Tribunais é no sentido de que: “Inadmissível a prolação de decreto condenatório se suficientes os elementos probatórios apenas para fundar suspeitas contra o réu. É que a simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade, não constitui, por si só, certeza” (JUTACRIM 45/218).

Portanto, considerando que não há prova testemunhal produzida em Juízo capaz de sustentar o édito condenatório em relação a LUCAS, sendo o conjunto probatório frágil para a condenação, impõe-se a aplicação do brocardo *in dubio pro reo*.

Portanto, considerando os relatos seguros das agentes penitenciárias, havendo provas suficientes nos autos a comprovar a autoria e a materialidade delitiva em relação a ELIZIANA, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a procedência da ação, com sua condenação, é a medida que se impõe.

Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal.

O crime de tráfico é apenado com reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, observo que a ré é primária, de modo que fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e

pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena estabelecida no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, uma vez que o delito foi cometido nas dependências da Penitenciária de Marília, de modo que aumento a pena em 1/6 (um sexto), alcançando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Ainda, entendo cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que a ré não se dedica a atividade criminosa, bem como sua não vinculação a organização criminosa, reduzo a pena em 2/3 (dois terço), resultando a reprimenda em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Pela inexistência de qualquer outra circunstância modificadora aplicável, torno a pena acima em definitiva. Diante das particularidades do caso concreto, atento ao princípio da individualização da pena, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena.

Presentes os requisitos do artigo 44, § 3º do Código Penal, substituo a pena privativa por duas penas restritivas de direito, consistentes em: a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo prazo da pena privativa de liberdade substituída, em local e condições indicados pela Central de Penas e Medidas Alternativas desta Comarca; b) LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA (artigo 43, VI do Código Penal), pelo que deverá a ré se manter recolhida em seu domicílio, pelo prazo da pena privativa de liberdade substituída.

Face à substituição da pena privativa de liberdade, incabível se mostra a suspensão de sua execução (artigo 77, III, do Código Penal).

Anoto, por fim, que os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes de infirmar a conclusão adotada no presente julgamento (artigo 315, §2º do Código de Processo Penal).

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, para, dando-a como incurso no artigo 33, caput, c/c 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, condenar ELIZIANA DOS SANTOS, já qualificada nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, SUBSTITUÍDA por duas penas restritivas de direito, consistentes em: a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo prazo da pena privativa de liberdade substituída, em local e condições indicados pela Central de Penas e Medidas Alternativas desta Comarca; b) LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA (artigo 43, VI do Código Penal), pelo que deverá a ré se manter recolhida em seu domicílio, pelo prazo da pena privativa de liberdade substituída, bem como ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

De outro lado, ABSOLVO o acusado LUCAS AGAPITO, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Sem custas, tendo em vista que a ré foi defendida por Patrono Dativo, justificando a concessão de assistência judiciária gratuita.

Por fim, considerando-se que a ré se encontra em liberdade e que foi condenada a cumprimento de pena em regime aberto, substituída por restritivas de direito, deverá assim permanecer caso deseje recorrer desta decisão.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE par atendimento do estabelecido no inciso III do artigo 15 da Constituição Federal.

Expeçam-se os ofícios de praxe.

P.I.C.

Marília, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA